

1501049-07.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501049-07.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501049-07.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVILY DA SILVA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

VISTOS.

DAVILY DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 16:45 horas, na Rua Uruguaiana, nº 1091, no Bairro Jardim Nova Iorque, nesta Cidade e Comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 62,22 gramas de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína (em pó e em pedras "crack"), e 26,50 gramas do composto tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis Sativa L, drogas capazes de causarem dependência.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar a fls. 138/146. A denúncia foi recebida a fls. 156/159. No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha

arrolada pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 234/241).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia (oralmente a fls. 243/237), ao passo que o Dr. Defensor, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto e a revogação da prisão preventiva (fls. 235/237).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudos de constatação prévia de entorpecente de fls. 17/19 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 86/87 e 90/94, os quais resultaram positivos para cocaína e maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Com efeito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime. Disse que estava desempregado e começou a vender drogas há cerca de dois meses antes dos fatos para poder sustentar sua filha. Toda a droga apreendida em sua residência lhe pertencia e seria destinada à venda. Trabalhava como servente antes de ficar desempregado. Nunca foi processado.

E a confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.

De fato, André Luis Peres Azevedo, ouvido em Juízo, disse que é policial civil e que havia notícias da prática de tráfico na residência descrita na denúncia. Diante disso, foi solicitado e deferido mandado de busca no local. No dia dos fatos deram cumprimento ao mandado. Chegando ao local, entraram pelo portão que estava entreaberto e encontraram o réu e um rapaz chamado Guilherme, sentados nos fundos da residência. Foram revistados e com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 141,00 em notas diversas. Com o outro rapaz nada de ilícito foi localizado. Indagado sobre a denúncia de tráfico, o réu disse que havia droga em uma cômoda, próxima de onde estavam. No local indicado localizaram 82 pinos com cocaína, 5 pedras de crack e três porções de maconha, duas maiores e uma menor. O réu disse que estava vendendo drogas há dois meses porque estava desempregado e precisava sustentar o filho menor.

Como se vê, o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que tinha em depósito 82 pinos com cocaína e 5 pedras de crack, totalizando 62,22 gramas da substância, bem como três porções de maconha, duas maiores e uma menor, pesando aproximadamente 26,5 gramas, tudo embalado individualmente e pronto para imediata comercialização. A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas já seriam suficientes, por si sós, para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Como já visto, também foi apreendida em poder do acusado a quantia de R\$ 141,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime. Não bastasse, o réu confessou em Juízo que a droga apreendida seria destinada à venda.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante

estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Atendendo, por outro lado, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, notadamente a elevada quantidade e variedade de droga apreendida (62,22 gramas de cocaína e 26,5 gramas de maconha), fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, presente a atenuante da confissão espontânea, reduz a pena ao patamar mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, entendo que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, conforme visto, o réu tinha em depósito uma elevada quantidade e variedade de entorpecente (82 pinos com cocaína e 5 pedras de crack, totalizando 62,22 gramas, e mais três porções de maconha, pesando aproximadamente 26,5 gramas). Além disso, segundo relatado pelo policial em Juízo, já havia notícias da prática de tráfico na residência, o que motivou o deferimento do mandado de busca e apreensão no local, tendo o réu, em juízo, confirmado que estava desempregado e vendendo drogas há pelo menos dois meses. Tais circunstâncias indicam que ele não se trata de um traficante ocasional, mas sim que se dedicava às atividades ilícitas, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDAS ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça possuem o entendimento de que a apreensão de vultosa quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006, visto indicar maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Em outros termos, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 2. Soa desarrazoado admitir que alguém preso em flagrante com mais de 8 kg de maconha ostente a condição de traficante eventual ou de pequeno traficante, de modo a ser merecedor da referida minorante.Precedentes. 3. A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes constitui elemento concreto e idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada, não obstante as penas-base tenham sido fixadas no mínimo legal. Precedentes. 4. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, I, do CP, haja vista que a reprimenda aplicada é superior a 4 anos de reclusão. 5. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AREsp 822.489/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018 - grifo meu).

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência" Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

O valor do dia multa, diante da situação econômica desfavorável do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DAVILY DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, justificável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu tinha em depósito uma grande quantidade e variedade de entorpecentes, não se enquadrando o delito na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já analisado), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, visto que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. No caso concreto, a insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito, o regime de pena imposto, e mormente o fato de o réu ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, deve ser observada a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 16, pois se tratam de produto do crime de tráfico de entorpecentes.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA